RASSEGNA GIURISPRUDENZA

Cass. 9.3.2021 n. 6395

FATTI DI CAUSA

Banca Alfa Spa impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso del credito IVA, acquisito dalla contribuente a seguito di cessione, ritualmente notificata, da parte della curatela del Fallimento Beta per eccedenza IVA riferita all'anno 2007.
L'Ufficio, nel costituirsi, eccepiva in compensazione l'esistenza di crediti erariali, di cui riservava l'esatta quantificazione.
Il ricorso era acconto dalla CTP di Catanzaro che riteneva non provata l'opposta compensazione.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate, la quale ribadiva e precisava l'ammontare dei crediti opposti in compensazione, pari all'importo di € 83.047,14, era rigettato dal giudice d'appello che escludeva "la possibilità di portare in compensazione obbligazioni tributarie diverse rispetto a quella" oggetto del thema decidendum del processo di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui la contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato con tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 57 DLgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 69 RD n. 2440 del 1923 e l'art. 38-bis DPR n. 633 del 1972.
1.1. In sostanza, l'Amministrazione finanziaria lamenta che la CTR abbia ritenuto non possibile la proponibilità dell'eccezione di compensazione del credito vantato dal contribuente in relazione ad altri controcrediti erariali, venendo così introdotte nel giudizio delle obbligazioni tributarie estranee all'originario thema decidendum.
Rileva, per contro, che detta eccezione, ammissibile ai sensi dell'art. 23 DLgs. n. 546 del 1992 ed integrante, in quanto tale, un fatto modificativo ed estintivo della pretesa del contribuente, era stata introdotta sin dal giudizio di primo grado e non aveva ampliato l'originario tema d'indagine fissato dalla parte con il ricorso introduttivo.
Sottolinea, sul punto, che, ai fini della tutela dei crediti tributari, l'Amministrazione finanziaria è legittimata anche a sospendere il pagamento dovuto al contribuente emettendo un provvedimento, di natura cautelare, di fermo amministrativo ex art. 69 RD n. 2440 del 1923, sicché consentita deve ritenersi l'eccepita compensazione.
1.2. La controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso, anche ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma c.p.c., attesa la non compensabilità, ex art. 56 L. fall., di un credito fiscale vantato da una procedura concorsuale, com'è quello ceduto, con un credito vantato dal Fisco ante procedura, sottolineando la novità delle norme invocate a sostegno della pretesa, sì da determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio.

Deduce, inoltre, la carenza di prova degli asseriti crediti erariali.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Occorre osservare, in primo luogo, che la doglianza mira a far valere un vizio strettamente processuale: la CTR ha escluso «la possibilità di portare in compensazione ... obbligazioni tributarie diverse rispetto a quella che costituiva il thema decidendum del processo di primo grado ... di contenuto del tutto autonomo rispetto al silenzio impugnato», ossia - e di ciò l'Agenzia si duole - della stessa possibilità di introdurre l'eccezione di compensazione per degli asseriti controcrediti perché verrebbero in rilievo profili estranei alla originaria obbligazione a fondamento della richiesta di rimborso, sicché si verrebbe ad allargare, illegittimamente, l'oggetto del giudizio.
2.2. Va sottolineato, in secondo luogo, che l'ufficio ha eccepito sin dal primo grado - con riproduzione di passaggi rilevanti per autosufficienza - l'invocata compensazione, allegando a tal fine la sussistenza di crediti erariali (all'epoca non ancora esattamente determinati nel loro ammontare), pretesa che, peraltro, la CTP riteneva di rigettare perché non provata. L'eccezione, poi, era riproposta in appello in termini più specifici (e producendo la documentazione ritenuta rilevante), con puntuale determinazione del quantum dell'eccezione stessa.
Lo stesso controricorrente (pag. 11), del resto, evidenzia che "nei propri scritti difensivi, l'ufficio ha sempre e solamente sostenuto che la presenza di asseriti carichi pendenti avrebbe legittimato la mancata erogazione del rimborso atteso l'operare della compensazione tra debiti e crediti".
Ne deriva che l'eccezione di compensazione era stata ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio ex art. 23 DLgs. n. 546 del 1992, non era stata dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado ed era stata precisata, con una emendatici, in sede d'appello.
2.3. La definizione del perimetro della censura comporta, invero, che deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità, che è articolata sul merito della dedotta compensazione, ossìa sulla sua infondatezza ex art. 56 L. fall., per essere gli opposti crediti sorti, rispettivamente, prima e dopo il fallimento.
Si tratta, infatti, di un profilo ulteriore e successivo rispetto alla ritualità e proponibilità, nel giudizio, della stessa eccezione.
2.4. Nel merito, appare opportuno prendere le mosse dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 2320 del 31.1.2020, che, nell'esaminare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria a tutela delle ragioni erariali, in ispecie, da un lato, l'art. 38-bis DPR n. 633 del 1972 (che prevede, ai fini dell'esecuzione di un rimborso, la prestazione di una garanzia) e, dall'altro, le misure di sospensione previste dall'art. 69 RD n. 2440 del 1923 (cd. fermo amministrativo) e dall'art. 23 DLgs. n. 472 del 1997, istituti che regolano la sospensione di un pagamento, per un'esistente eccedenza di IVA, ai fini della sua eventuale compensazione con altra partita attiva dell'Erario, afferma un principio di alternatività: a fronte della prestazione della garanzia ed in costanza di sua validità, il fermo cautelare non può essere opposto, e, viceversa, potrà essere opposto nei casi di assenza di garanzia.
In altri termini, per quanto qui rileva, ove non sia stata prestata la garanzia ex art. 38-bis cit., l'Amministrazione può adottare un provvedimento di sospensione che mira a salvaguardare l'eventuale compensazione legale del credito che abbia o pretenda di avere con quello del contribuente suo creditore.
La strumentalità di tali mezzi comporta che il giudice tributario, davanti al quale sia impugnato il provvedimento di sospensione, non può limitarsi ad annullare il provvedimento,

ma deve esaminare il merito dell'eccezione di compensazione a cui esso è strumentale (v. Cass. n. 19335 del 29.9.2016; Cass. SS.UU. n. 7945 del 21.5.2003).
2.5. È evidente, dunque, che l'Amministrazione, anche nel caso in cui non abbia adottato un provvedimento di fermo o di sospensione del rimborso, conserva la possibilità di opporre direttamente - nel giudizio che sia stato avviato nei confronti del diniego di rimborso (e, in ispecie, in caso di silenzio-rifiuto) - l'eccezione di compensazione che, se ritualmente e tempestivamente proposta, costituisce una eccezione in senso stretto (di merito) e non un indebito ampliamento dell'oggetto del giudizio.
Ha dunque errato la CTR ad escludere la possibilità di eccepire, nel giudizio relativo al rimborso, la compensazione rispetto ad altri crediti erariali.
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame.
4. Il ricorso incidentale condizionato - con il quale si denuncia la violazione degli artt. 56 L. fall., 1241 e 1260 c.c., 115 c.p.c. (primo motivo), 2697 c.c. (secondo motivo) e omessa pronuncia (terzo motivo - è, invece, inammissibile per carenza d'interesse, venendo in rilievo questioni, relative al merito e alla fondatezza dell'eccepita compensazione, rimaste assorbite dalla statuizione principale della CTR, sicché in relazione ad esse manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 22.9.2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.